

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제03절 소송상의 대리인>

<제5편 병합소송.제12장 다수당사자소송.제01절 공동소송>

[기출][2013-1-1]도급계약상 연대책임 관계인 공동 피고에 대한 임금청구소송에서 소송대리인의 대리권 범위

《[문제1] 乙과 丙은 도급계약에 따라 함께 사업을 수행하고 있고, 임금지급에 대하여 연대책임 관계에 있다. 그런데 수급인인 丙은 소속 근로자인 甲에게 임금을 지급하지 못하고 있다. 이에 甲은 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기하였다. 이때 다음 물음에 대하여 각각 논하시오. (50점)》

(문제1) 위 소송에서 甲이 변호사 A를 소송대리인으로 선임한 경우 소송대리인 A의 대리권의 범위는? (20점)》

<문제1의 물음1> 도급계약상 연대책임 관계인 공동 피고에 대한 임금청구소송에서 소송대리인의 대리권 범위

I. 문제의 제기

- 사안은 丙의 근로자인 甲이 임금을 지급받지 못하자 도급계약 관계인 乙과 丙을 공동 피고로 하여 임금청구의 소를 제기한 상황이다. 쟁점으로 <원고 甲이 공동 피고 乙과 丙을 상대로 선임한 소송대리인인 변호사 A의 대리권의 범위가 어디까지인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소송대리인의 일반적인 대리권의 범위, 특별수권이 필요한 사항, 소송대리권의 제한 가능성 여부에 대하여 설명한다.

II. 소송대리권의 범위에 관한 법리

1. 일반적 소송대리권의 범위

(1) 법정 대리권의 의의

- "민사소송법 제90조 제1항"에 의하면 소송물에 관한 양도나 대리권의 제한이 없는 한 당해 소송에 관한 모든 소송행위를 할 수 있는 권한을 가진다. 이는 소송계속 중 발생하는 대내외적인 변론, 증거신청, 기일지정 신청 및 상대방의 소송행위에 대한 대응 등을 모두 포함한다.

(2) 심급대리의 원칙

- 소송대리인의 대리권은 특별한 약정이 없는 한 수임한 당해 심급의 소송절차에만 한정된다. 따라서 제1심에서 선임된 소송대리인의 대리권은 제1심의 종국판결이 대리인에게 송달됨으로써 원칙적으로 소멸하며, 판결 송달 전이라 하더라도 상소심의 소송절차에는 대리권의 효력이 미치지 않는다.

2. 특별수권사항의 범위와 내용

(1) 특별수권의 필요성

- "민사소송법 제90조 제2항"은 당사자의 처분권과 직결되거나 당사자에게 중대한 불이익을 초래할 수 있는 일정한 소송행위에 대하여는 본인의 특별한 권한의 위임(특별수권)을 받도록 강제하고 있다.

(2) 구체적 법정 사항

- 특별수권이 있어야만 대리인이 행할 수 있는 행위는 다음과 같다. ❶ 반소의 제기. ❷ 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙 또는 제80조의 규정에 따른 탈퇴. ❸ 상소의 제기 또는 취하. ❹ 대리인의 선임.

3. 소송대리권 제한의 효력

(1) 대리권 제한의 원칙적 무효

- "민사소송법 제91조 본문"에 의하면 변호사인 소송대리인의 소송대리권은 당사자의 사적 합의로 제한하지 못한다. 법정된 일반적 소송대리권에 가한 당사자 간의 사적인 제한은 법원이나 상대방에 대하여 효력이 없다. 이는 소송대리인의 자격을 신뢰한 법원과 상대방을 보호하고 소송절차의 확실적 안정을 도모하기 위함이다.

(2) 소송외적 제한의 상대적 효력

- 다만, 사적인 제한이라도 당사자 내부 관계에서는 채무불이행에 따른 민사상 손해배상책임 등의 원인이 될 수 있을 뿐이다. 또한, 특별수권사항("민사소송법 제90조 제2항")에 대하여 대리권을 별도로 수여하지 않기로 하는 것은 애초에 법정 소송대리권에 가해지는 소송법상의 사적 제한이 아니므로, 수권하지 않거나 제외하는 약정은 전적으로 유효하다.

III. 사안의 적용

1. 일반대리권의 범위

(1) 대리권 행사의 주체

- 원고 甲의 소송대리인 변호사 A는 특별한 사정이 없는 한 제1심 소송절차의 종국판결 송달 시까지 甲을 대리하여 소송행위를 수행할 법정 대리권을 가진다.

(2) 공동소송에서의 대리관계

- 乙과 丙은 임금지급에 대한 연대책임 관계에 있어 통상공동소송 관계에 해당한다. 소송대리인 A는 공동피고 乙과 丙 모두에 대하여 甲의 임금채권을 관철하기 위한 변론, 증거조사 신청, 준비서면 제출 등의 소송행위를 대리인으로서 적법하게 수행할 수 있다.

2. 특별수권의 범위

(1) 특별수권 유무에 따른 판단

- A가 乙이나 丙 중 일부에 대하여 소를 취하하거나, 법정에서 화해를 하거나, 청구의 포기·인낙을 하고자 하는 경우, 또는 패소 시 상소를 제기하고자 하는 경우에는 원고 甲으로부터 별도의 특별수권을 받아야만 한다. 특별수권이 없는 상태에서 행한 처분행위는 무권대리행위로서 무효이다.

(2) 대리권의 제한 요건

- 설령 甲이 A를 선임하면서 '상대방 乙에 대해서만 소송행위를 하고 丙에 대해서는 적극적으로 다루지 말 것'이라는 식으로 일반 대리권 범위를 제한하는 내부 계약을 체결하였더라도, 이러한 사적 제한은 "민사소송법 제91조 본문"에 의하여 수소법원과 상대방인 乙·丙에게 전적으로 효력이 없다.

IV. 결론

- 변호사 A의 소송대리권은 법정 심급대리 원칙에 따라 제1심 소송절차 전반에 미치며, 공동피고 乙과 丙 모두를 상대로 甲의 권리를 옹호하기 위한 변론 및 기일지정 등 일반적 소송행위 일체를 대리할 수 있다. 다만, 소의 취하, 화해, 청구의 포기·인낙, 상소의 제기 등 당사자의 처분권과 직결된 법정 특별수권사항에 대해서는 甲의 구체적인 특별위임이 있어야만 대리권을 행사할 수 있으며, 이외에 법정 대리권에 가해진 사적 제한은 "민사소송법 제91조"에 따라 소송법상 모두 무효이다.